

	<문제-1> [51회 특허법 기출문제 풀이]
[문제]	
	(1) §128①의 성격 (2) 손해액 산정 (3) 손해액의 제한 (4) 손해액의 공제
[답안]	
I. 설문(1) - § 128①의 성격	
1. 서설 - 입증책임의 완화 내지 전환	
	i) 특허침해로 인한 손해배상청구는 원칙적으로 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상청구의 문제이나 침해사실 및 손해액의 입증이 일반재산권 침해에 비해 훨씬 곤란하기 때문에 특허법은 입증책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액의 추정 규정(法128)을 두고 있다. ii) 설문(1)에서는 제128조 규정 중 제1항의 성격과 관련하여 구체적으로 살펴본다.
2. 성격	
	(1)특허권 침해로 인하여 특허권자의 이익이 감소하는 경우 중 판매수량의 감소는 원칙적으로 특허침해에 의하여 특허권자의 판매가 감소하였다는 점을 증명한 후, 그에 따른 특허권자의 일실�이익을 산정하여야 한다.
	(2)다만, 제128조제1항에서는 침해자의 판매수량 모두를 특허권자의 판매감소량으로 볼 수 있으며, 침해자의 판매수량만 확인한다면, 침해자의 단위이익액을 몰라도 특허권자의 단위 이익액을 이용할 수 있다는 장점이 있다.
	(3)제128조제1항은 특허법 제2조에서 발명의 실시와 관련하여 3가지로 분류된 발명의 범주 중 물건의 발명에 대하여 적용됨이 법문상 명확하다.
	(4)제128조제1항에서는 “할 수 있다” 라는 표현을 사용하므로 추정규정으로 볼 것인지 간주 규정으로 볼 것인지에 대한 견해대립이 있으나, 반

	증을 허락하지 않는 것은 과도한 손해배상액의 인정이 되므로 추정으로 보는 것이 타당하다.
3. 결어	
	제128조제1항에 의하면, 특허권자의 생산성이 높을수록 더 많은 손해배상을 구할 수 있게 되며, 제128조제2항에 의한 청구에서 침해자의 생산성이 높을수록 더 많은 손해배상을 구할 수 있는 것과는 대조되는 것으로 보인다.
II. 설문(2) - 제128조 제1항 제1문에 따른 손해액의 산정	
1. 침해행위를 하게 한 물건을 양도	
	i) 제128조제1항 제1문을 적용하기 위해서는 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 사실이 필요하다. ii) "침해행위를 하게 한 물건"은 특허제품을 의미하며, iii) "양도"라 함은 생산된 발명품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것으로서 양도의 수량이나, 대상, 양도의 형태 등은 문제되지 않는다.
2. 양도수량	
	침해자가 양도한 침해제품의 수량을 증명함에 있어서, 관련 자료는 모두 침해자 측에서 가지고 있을 것이므로 제132조의 서류제출명령을 활용할 수 있을 것이다.
3. 단위수량당 이익액	
	i) 단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정된 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 의미한다. ii) 判例 역시 단위수량당 이익액은 침해가 없었다면 의장권자가 판매할 수

	있었을 것으로 보이는 의장권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말한다고 하였다.
	4. 설문(2)의 해결 - 120억
	(1) [양도수량] i) 피고가 생산한 15만 개의 침해제품 중 판매한 10만개, 무상 배포한 2만개는 제128조제1항 제1문에서 규정하는 양도수량에 해당되나 ii) 창고에 보관 중인 3만개의 침해제품은 양도수량에 해당되지 않으므로 iii) 피고가 양도한 침해제품의 양도수량은 총 12만개이다.
	(2) [단위수량당 이익액] 원고의 가방 1개당 판매이익액은 평균 10만원이므로 제128조제1항에서 규정하는 단위수량당 이익액은 10만원이다.
	(3) [결론] 결과적으로, 출원공개를 통하여 과실이 추정되며, 피고는 침해제품을 양도하였는바 침해제품의 양도 수량(12만개)에 단위수량당 이익액(10만원)을 곱한 금액인 120억이 제128조제1항 제1문의 손해액에 해당된다.
	Ⅲ. 설문(3) - 제128조 제1항 제2문에 따른 손해액의 제한
	1. 손해액 제한
	i) 특허권자의 생산능력을 벗어난 범위에서 침해자가 생산, 판매한 경우에는 그 범위는 손해배상액의 산정의 기초로 할 수 없다. ii) 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 생산한 물건에까지 특허권자가 생산하여 판매할 수 있었다고 가정하는 것은 불합리하기 때문에 제한하고 있다.
	2. 생산능력
	특허권자의 생산능력이란 특허권자가 자신의 유희설비로 추가 생산할 수

	있었던 수량을 말하며, 새로운 투자와 노동자의 고용 및 훈련을 요하지 않고, 생산, 판매할 수 있는 수량을 의미한다.
3. 설문(3)의 해결 - 50억	
	(1) [생산능력] 특허권자인 원고는 침해행위가 있기 전 매년 6만개의 가방을 판매하였으므로, 침해소송 제기 전 지난 5년간 생산할 수 있었던 수량은 30만개가 된다.
	(2) [실제 판매한 물건의 수량] 특허권자인 원고는 침해행위 이후로 매년 5만개의 가방을 판매하였으므로 침해기간 동안인 5년간 실제 판매한 물건의 수량은 25만개가 된다.
	(3) [결론] 결과적으로, 침해기간 동안 특허권자인 원고가 생산할 수 있었던 30만개에서 실제 판매한 25만개를 뺀 수량인 5만개에서 설문(2)에서 살펴본 단위수량당 이익액인 10만원을 곱한 50억이 제128조제1항 제2문에 따른 손해액의 제한(상한액)이 되는 것이다.
IV. 설문(4) - 제128조 제1항 제3문에 따른 손해액의 공제	
1. 손해액의 공제	
	i) 침해행위 외의 사유로 특허권자가 특허제품을 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그 수량에 따른 금액을 손해액에서 빼야한다. ii) 침해자로 지목된 피고에게 증명책임을 지우기 위해 단서로 규정되어 있다.
2. 침해행위 외에 판매할 수 없었던 사정(구체적 사유)	
	침해자의 시장개발 노력, 침해품의 품질의 우수성, 광고, 지명도 및 대체품의 존재와 함께 특허제품의 수요의 부존재 등이 있다.
3. 判例의 태도	

	判例는 의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조
	제1항 단서의 사유에는 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과
	시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이 포함될 수 있다고 하였다.
	4. 설문(4)의 해결 - 72억
	소외 제3자는 원고의 특허권을 침해하지 않는 경쟁제품을 판매하고 있
	으므로 判例에 따를 때 이와 같은 사실은 피고의 침해행위 외에 판매할
	수 없었던 사정으로 볼 수 있다. 설문(2)에서 산정된 손해액인 120억 중
	소외 제3자의 시장점유율에 해당하는 40%는 공제될 것이므로, 나머지
	60%에 대한 금액인 72억이 원고의 손해액이 될 것이다. 다만, 상기 설문
	(3)에서 살펴본 바와 같이, 원고의 손해액은 50억이 상한에 해당되는바
	50억까지 배상받을 수 있을 것으로 판단된다. [끝]
	<문제-2>
	[문제]
	(1) 甲의 실시가 직접침해인지 여부 (2) 乙의 실시가 간접침해인지 여부
	[답안]
	I. 설문(1) - 甲의 실시행위가 직접침해인지 여부
	1. 甲의 실시태양
	甲은 i)2012년부터 2013년 초반까지 제품을 연구개발하는 실시(이하,
	제 1 실시) ii)2013년 초반부터 2013년 12월 31일까지 제품을 생산하는
	실시(이하, 제 2 실시) 및 iii)2014년 1월 1일부터는 제품을 생산 및 판

	매하는 실시(이하, 제 3 실시)를 하고 있다.
2. 설문과 관련된 침해성립요건	
(1) 특허권이 유효할 것	
	특허권의 침해가 성립하기 위해서는 특허권의 존속 중 실시이어야 한다.
(2) 보호범위 이내의 실시일 것	
	①원칙적으로 특허청구범위는 필수구성요건만으로 이루어지므로 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 침해가 된다(구성요건 완비의 원칙). ②다만, 구성요건이 문언 상 일치하지 않으나 실질적 기술적 가치가 균등한 발명으로 i)과제해결의 동일성 ii)치환가능성 iii)치환용이성을 만족하는 경우에는 보호범위 이내의 실시가 될 수 있다(균등론).
(3) 정당한 권원이 없을 것	
	§96①(1)에 따라 연구 또는 시험을 하는 행위는 i)영리를 목적으로 하지 않고, ii)학술의 진보발전에 공헌하므로 침해가 아니다.
4. 甲의 실시행위가 직접침해인지 여부	
(1) 제 1 실시 - 제품을 연구 개발하는 실시	
	i)2012년부터 2013년 초반까지 甲의 권리는 유효하다. ii)기본적으로 甲의 연구개발을 위한 실시는 원고의 특허권을 침해하는 것으로 판단되나 iii)甲이 원고의 특허발명자체를 연구 또는 시험하는 행위는 §96①(1)에 해당하므로, 침해가 성립되지 않을 것이다.
(2) 제 2 실시 - 제품을 생산하는 실시	
	i)甲의 권리는 유효하고 ii)§96①(1)에 해당하더라도 결과물을 특허권 침해가 되는 태양으로 판매하는 것에는 정당권원이 인정되지 않는다. iii)

	단, 보호범위와 관련하여 ①甲의 실시발명이 원고의 특허발명을 그대로 포함하거나 전술한 요건에 따른 균등물에 해당하는 경우에는 침해가 성립하고, ②그 이외의 경우에는 침해가 성립하지 않을 것이다.
	(3) 제 3 실시 - 2014.1.1 이후 제품을 생산 및 판매하는 실시
	2014년 1월 1일에는 이미 甲의 특허권은 소멸하였으므로, 甲의 특허권은 유효하지 않아 제 3 실시는 침해가 되지 않는다.
	Ⅱ. 설문(2) - 乙의 실시행위가 간접침해인지 여부
	1. 간접침해의 인정취지
	직접침해는 아니지만 직접침해에 고도의 개연성이 있는 행위에 대해 특허권의 실질적 보호를 위해 간접침해를 인정하고 있다(§127).
	2. 간접침해가 직접침해를 전제로 하는지 여부
	(1)학설은 i)간접침해는 직접침해가 있어야만 성립한다는 견해(종속설)와 ii)간접침해는 직접침해와 관계없이 성립한다는 견해(독립설)가 대립된다.
	(2)생각건대 간접침해의 취치는 직접침해 전 단계의 예비적 행위를 방지하여 특허권자를 두텁게 보호하기 위한 것이므로, 독립설에 따라 직접침해를 전제로 하지 않는다고 보는 것이 타당하다.
	3. 타용도의 의미 및 판단방법
	(1)타용도가 있다는 의미는 간접침해대상물을 그러한 용도로 사용한 결과 특허발명의 직접침해가 성립되지 않는 경우가 존재하는 것을 의미한다.
	(2)타용도의 판단방법과 관련하여, ①사용가능성설과 사용사실설 등이 대립되나 ②判例는 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 타용도가 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

4. 乙의 실시행위가 간접침해에 해당하는지 여부	
(1) 간접침해가 직접침해를 전제로 하는지 여부에 대한 논점	
독립설에 따라 간접침해의 성립에 있어 특허발명의 실시만이 요구될 뿐, 특허발명의 실시로 직접침해가 성립할 필요는 없다. 따라서 맞춤형 전원공급장치의 결과물인 전자칠판의 침해여부와 무관하게 이하에서는 맞춤형 전원공급장치의 타용도가 존재하는지 여부에 따라 독립적인 간접침해 여부를 검토한다.	
(2) 타용도의 판단 - 설문(1)의 甲의 실시행위가 직접침해인 경우	
i) 간접침해대상물인 맞춤형 전원공급장치가 적용된 결과물인 甲의 전자칠판의 실시는 원고의 전자칠판에 대해 직접침해가 성립된다. ii) 따라서 甲의 전자칠판에 맞춤형 전원공급장치가 적용되는 것은 타용도가 발생한 것이 아니고, iii) 시장 점유율이 60%라는 사실만으로도 타용도가 발생했다고 보기는 어려우므로, iv) 결국 乙의 실시행위는 원고의 특허발명에 대해 간접침해가 된다.	
(3) 타용도의 판단 - 설문(1)의 甲의 실시행위가 직접침해가 아닌 경우	
i) 맞춤형 전원공급장치가 적용된 甲의 전자칠판의 실시는 원고의 전자칠판에 대해 직접침해가 성립되지 않고 ii) 사용사실설에 따른 상업적, 경제적, 실용적 사용 사실이 인정되어 타용도가 존재하게 된다. iii) 따라서 乙의 실시행위는 원고의 특허발명에 대해 간접침해가 되지 않는다. [끝]	
<문제-3>	
[문제]	
(1) 진보성 판단의 구체적 기준 (2) 특허청구범위의 해석 (3) 상업적 성	

	공과 진보성 판단의 관계 (4) 다른 기술분야의 선행기술과 진보성 판단
	[답안]
	I. 설문(1) - 결합발명의 진보성 판단방법
	1. 甲의 출원발명의 성격
	甲의 출원발명은 정보통신 분야 내 새로운 서비스 제공 요구라는 기술적 과제를
	달성하기 위하여 선행기술 3개를 합하여 이루어진 발명이므로 결합발명에 해당한다.
	2. 일반적인 진보성 판단기준 및 결합발명의 진보성 판단기준
	(1)진보성 판단은 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성, 발명의 작용·효과
	및 목적을 고려하여 종합적으로 판단하되, 구성의 곤란성, 효과의 현저성
	및 목적의 특이성을 참작하여 통상의 기술자로부터 용이한지 여부로 판단한다.
	(2)判例는, 출원발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가
	유기적으로 결합된 전체 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이며,
	그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 과제해결원리에 기초하여
	유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져야 하고, 이때 결합된
	전체 구성이 갖는 특유한 효과의 현저성도 고려해야 한다고 판시하였다.
	3. 결합발명의 구성의 곤란성 및 효과의 현저성 판단 방법
	(1)결합발명의 구성의 곤란성은 구성요소 각각이 공개되었다고 하더라도
	그 결합이 통상의 기술자에게 용이한 지 여부로 판단하며, 통상의 기술
	자에게 용이한 지 여부는 결합발명을 이루는 각 구성 간 결합에 대한 암
	시, 동기 등이 선행기술에 제시되어 있는 지 여부로 판단한다.
	(2)결합발명의 효과의 현저성은 각 기술적 구성을 결합함으로써 그 결합
	된 구성이 각각의 선행기술에 제시된 효과의 합과는 다른 상승된 효과를

	발휘하는 경우 인정된다.
4. 설문(1)의 해결	
	甲의 출원발명인 결합발명을 구성·효과 등을 중심으로 진보성을 판단하기 위해서는, i)甲의 온라인 서비스 관련 발명을 구성하는 선행기술 3개의 결합이 통상의 기술자에게 자명한지 여부로 판단하여야 할 것이며, ii)그 뿐만 아니라 선행기술 3개의 결합에 따른 효과가 3개의 선행기술 각각의 효과를 뛰어넘는 현저한 효과가 있는 지 여부를 고려하여 판단하여야 할 것이다.
Ⅱ. 설문(2) - 특허청구범위의 해석방법	
1. 특허청구범위의 기재내용 및 특허청구범위의 해석방법	
	(1)특허청구범위에는 ① 청구항이 1또는 2이상 있어야 하며, ②그 청구항은 i) 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고, ii) 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있어야 하며(法42조4항), ③보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요한 구조·방법 등을 기재하여야 한다(法42조6항)
	(2)判例는, 진보성 판단의 대상이 되는 출원발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고, 특허청구범위를 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다고 판시하였다.
	(3)다만, 判例는 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다고 판시하였다.
	(4)생각건대, 특허청구범위는 특허출원인이 보호받고자 하는 사항을 기재

	하는 것이므로, 특허청구범위에 기재된 사항이 명확하다면 원칙적으로는
	특허청구범위에 기재된 사항을 출원심사의 대상으로 삼아야 할 것이나,
	그 발명의 명확한 기술적 의미 이해를 위해 필요한 경우에는 발명의 상
	세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의해 제한적으로 해석하여야 할 것
	이므로 판례의 태도는 타당하다고 판단된다.
2. 설문(2)의 해결	
	①사안의 경우 甲의 온라인 서비스 관련 발명은 기재 자체만으로 발명이
	명확하게 이해될 수 있도록 특허청구범위가 작성되었으므로, 원칙적으로
	는 특허청구범위에 기재된 구성을 이용하여 출원발명을 확정하여야 할
	것이나, ②전문가의 조언을 고려할 때 온라인 서비스 관련 발명의 기술
	적 의미 이해를 위해 특허청구범위가 발명의 상세한 설명이나 도면 등
	다른 기재에 의해 제한적으로 해석되어야 할 필요성이 있다고 보여지므
	로, ③특허요건 판단을 위한 출원발명 확정 시 발명의 상세한 설명 및
	도면 등을 참작하여 온라인 서비스 관련 발명의 기술적 의의를 고찰한
	다음 객관적·합리적으로 그 대상을 해석하여야 할 것으로 판단된다.
Ⅱ. 설문(3) - 상업적 성공과 진보성 판단의 관계	
1. 문제의 소재	
	출원발명이 상업적으로 성공하였다는 객관적인 사실이 진보성 인정여부
	라는 법률적 사실에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 판례의 태도를 중심
	으로 상업적 성공과 진보성 판단의 관계를 검토하기로 한다.
2. 진보성 판단의 원칙 및 다른 요인을 고려할 수 있는지 여부	
	(1)진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성

	및 작용·효과를 중심으로 검토하되, 구성의 곤란성, 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 종합적으로 판단하는 것이다.
	(2)다만, 심사지침서 및 判例는 진보성을 판단함에 있어서는 진보성 인정에 영향을 미치는 여러 가지 다른 요인이 있을 수 있으므로 상업적 성공과 같은 이러한 다른 요인을 진보성 판단에 고려할 수 있다는 입장이다.
	3. 상업적 성공과 진보성 판단의 관계
	(1)判例는, 발명이 상업적으로 성공하였다는 사정은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수는 있으나, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 상업적 성공이 발명이 기술적 특징으로부터 비롯된 것이 아니라 판매기술의 개선, 광고 등과 같은 다른 요인에 의해 얻어진 것이라면 진보성 판단의 참고자료로 삼을 수 없다고 한다.
	(2)생각건대, 상업적 성공이 발명의 기술적 요소가 아닌 마케팅 기법 등에 의하여 이루어진 경우 이를 지나치게 인정하면 진보성 판단기준이 발명의 기술적 요소가 아닌 다른 요소에 의하여 대체되는 결과가 초래될 수도 있으므로, 진보성 판단의 2차적 요소로 활용하는 판례의 태도가 타당하다.
	4. 설문(3)의 해결
	진보성 판단 시 상업적 성공 사실만으로 진보성을 인정할 수는 없을 것이나, 상업적 성공이 오로지 발명의 기술적 요소에 의해 이루어진 것이라면 상업적 성공 사실을 진보성 판단에 참작할 수는 있는 관계라고 할 수 있다.
	Ⅱ. 설문(4) - 출원발명과 상이한 기술분야의 인용발명 이용가부
	1. 출원발명과 상이한 기술분야의 발명을 인용발명으로 이용가능한지 여부
	(1)判例는, 法29조2항에서 의미하는 기술분야는, 특허발명이 이용되는 기

	술분야를 말하는 것으로서, 원칙적으로 다른 기술분야의 발명은 인용발명으로 사용되기 어려울 것이나, 다만 다른 기술분야 발명의 기술구성이 특정 기술분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니며, 당해 특허발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명이 당면한 기술문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 상이한 기술분야라도 인용발명이 될 수 있다고 판시하였다. (2)심사지침서도 출원발명과 상이한 기술분야의 발명을 진보성 판단의 인용발명으로 이용하는 것이 가능하며, 이 경우, 출원발명과 인용발명 간 i)기술분야의 관련성 ii)과제해결원리 및 기능의 동일성 등 인용발명으로 이용가능한지에 대한 타당성을 충분히 검토하여야 한다고 한다. (3)또한, '기술분야의 관련성' 요건은 i)인용발명이 다른 기술분야에서 사용될 가능성이 있거나 ii)통상의 기술자가 과제해결을 위해 그 인용발명을 참고할 가능성이 있는 경우 충족되는 것으로 판단한다. 2. 설문(4)의 해결 사안의 선행기술이 甲출원발명의 기술분야인 온라인 서비스 분야에 속하지 않는다고 하더라도, 그 선행기술이 i)특정 기술분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니며 ii)온라인 서비스 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 그 선행기술을 이용하여 甲출원발명의 진보성을 부정할 수 있을 것이다.
	<문제-4>

[문제]

(1) 진보성 하자 관련 침해소송에서의 乙의 항변 (2) 균등론 관련 乙의 대응방안

[답안]

I. 설문(1) - 침해소송에서 乙이 항변할 수 있는 법적방안

1. 乙이 침해소송에서 진보성의 무효사유를 주장할 수 있는지 여부

(1)判例는 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 침해소송을 심리하는 법원은 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다고 판시하였다.

(2)따라서 乙이 특허침해소송에서 진보성의 하자를 주장하는 것은 허용된다.

2. 乙이 하자가 있는 특허권을 당연 무효라고 주장할 수 있는지 여부

(1)判例는 등록실용신안은 등록이 된 이상 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 무효사유가 있더라도 다른 절차에서 당연무효라고 판단할 수 없다고 하였다.

(2)① i)특허법은 등록주의를 채택하고 있고 ii)특허청과 법원의 권한 분배의 원칙을 고려할 때, 상기 判例는 타당하다. ②따라서 乙은 甲의 특허권이 당연 무효라고 주장할 수는 없다고 판단된다.

3. 진보성의 하자있는 특허권의 권리범위가 부정됨을 주장할 수 있는지 여부

(1)判例는 출원 당시에 특허 발명이 공지공용인 경우 무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시하였다.

(2)생각건대, i)진보성(§29②) 및 특허법의 입법 목적(§1)의 취지를 고려하고, ii)진보성이 없는 경우까지 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 기존의 판결들을 권리남용과 관련된 판결의 견해에 배치되는 범위에서 변경한다는 판례의 입장을 고려할 때, 진보성의 하자가

	있는 특허 발명의 권리범위도 인정하지 않는 것이 타당하다.
	(3)따라서 乙이 甲의 특허권의 권리범위가 부정됨을 주장하는 것은 가능하다.
4. 乙의 권리남용의 항변이 가능한지 여부	
	(1)判例는 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우, 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당된다고 판시하였다.
	(2)생각건대, i)진보성(§29②)의 취지 및 특허법의 입법 목적(§1)을 고려하고, ii)특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다는 점을 고려할 때, 상기 判例의 태도가 타당하다.
	(3)따라서 乙이 甲의 권리행사에 대해 권리남용을 주장하는 것은 가능하다.
Ⅱ. 설문(2) - 균등론 주장에 대한 乙의 대응방안	
1. 균등론의 인정취지 및 성립요건	
	(1)균등론은 특허권자를 보호하고 구체적 타당성을 위해 경험적으로 발전되어 온 이론이다.
	(2)判例는 특허권자가 입증해야 하는 적극적 요건으로 i)과제해결의 동일성 ii)치환가능성 iii)치환용이성을 요구하고, 실시자가 입증해야 하는 소극적 요건으로 i)자유기술에 해당하지 않을 것 ii)의식적으로 제외되지 않을 것이 요구한다.
2. 乙의 대응방안 - 균등물이 아니라는 주장	
	i)치환된 부분이 특허발명의 본질적 부분이어서 과제해결의 동일성이 인정되지 않거나 ii)치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 않아 치환가능성이 없거나 iii)치환하는 것이 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있을 정도로 자명하

	지 않아 치환용이성이 인정되지 않는 경우, 乙이 실시하고 있는 발명은 甲의 특허발명과 대비하여 균등물이 아니라는 주장을 할 수 있다.
	3. 乙의 대응방안 - 의식적으로 제외되었다는 사실의 주장
	(1) 甲의 보정은 신규성, 진보성 등의 선행기술회피를 위한 보정이므로, 보정의 유형과 관련된 논란없이 의식적 제외설의 적용이 가능하다.
	(2) 의식적 제외의 범위와 관련하여, 判例는 명세서뿐만 아니라 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 의식적으로 제외된 것 인지를 확정하여야 한다고 판시하여, 유연한 기준의 입장을 지지하고 있다.
	(3) 생각건대 의식적 제외의 개념을 엄격히 적용하면 균등론이 인정될 가능성이 적어져 특허권자의 보호가 미흡해지는 문제점이 발생할 수 있으므로, 유연한 기준의 입장에 따라 의식적 제외설의 적용여부를 판단하는 것이 타당하다.
	(4) 유연한 기준의 입장에서 판단해볼 때, 甲이 특허청구범위가 넓다는 심사관의 지적에 대응하여 권리범위가 좁아질 수 있다는 사실을 충분히 고려한 상태에서 특허청구범위를 축소 보정한 사실이 인정되므로, 乙은 의식적제외설에 따라 甲의 침해주장은 부당하다는 대응을 할 수 있다.
	4. 乙의 대응방안 - 자유기술의 항변
	(1) 判例는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하고 있다.
	(2) 따라서 乙이 실시하고 있는 발명이 출원 전에 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다면, 判例에 따라 자유기술의 항변을 할 수 있다. [끝]
	이하여백